

【文章编号】1002—6274(2026)01—003—16

数据跨境流动国际法规制与中国应对^{*}

马忠法

(复旦大学法学院,上海 200438)

【内容摘要】数据跨境流动趋势不可避免,其影响个人隐私、国家安全和经济发展(含数据垄断)等事宜;对此,各国或地区采取的规制措施略有不同:欧盟偏重保护人权,尤以保护个人隐私为特色,美国当下倾向于限定性的数据自由流动,中国强调安全可控情形下的自由流动。而数据跨境流动的国际法规制呈碎片化状况,无全球统一的条约调整,相关规范分散于区域性自由贸易协议中;内容仍集中于国家安全、个人隐私、经济发展等。国内层面,中国应在统筹安全、发展与隐私保护原则下,完善相关国内立法,以自贸区为试点对接高标准国际数据贸易规则,为引领该领域国际规则的发展与完善创造积极条件;国际层面,应主动参与国际合作,充分发挥现有区域性规则的作用,确保数据保护、监管机制优化与自由流动的平衡,参与甚或引领国际数据贸易规则尤其是全球多边数据跨境流动协议之形成,以最大程度实现数据贸易利益,造福各国人民。

【关键词】数据跨境流动 国际法规制 国家安全 个人隐私

【中图分类号】DF96 【文献标识码】A

引言

与数据跨境流动^①相关的数字技术^②正在重塑我们的工作和贸易方式,它既创造了机遇,也带来了风险;与其相关的国际法规制及相应的国际组织在推动建立相关监管和政策框架方面可以发挥重要作用,该框架既能鼓励先进的数字技术之应用,又能降低潜在风险。数字技术之下,数据具有天然的跨境流动性,否则其就失去了意义。数据是当下数字贸易的根基,它支持数字贸易的自由移动;数字贸易中,它是一种生产资料,也是可以交易的资产,更是组织全球价值链和提供服务的手段。它还通过促进实施贸易便利化来间接地支持实物贸易。数据已经成为世界主要经济体关注贸易、投资的核心内容之一,它是新时代石油,关键不在于权属,而在于运用。但如果规制不善,数据泄露则风险无比巨大,损失极其惨重。数据跨境流动涉及的主要法律问题是“个人隐私”“国家安全”及“经济发展(主要是垄断问题)”。就个人而言,数据跨境流动的风险是其个人敏感数据的泄露;而就国家而言,数据跨境流动出现问题主要影响国家

安全和社会稳定;就企业而言,可能面对数据垄断、合规等而带来巨大风险。数字技术强国利用其优势,要么通过倾销数据产品夺取他国财富,要么在其出口的数据产品或提供的数据服务中设置陷阱,带来破坏。^[1] 这些方面的典型之例有:1982年6月,苏联西伯利亚输气管道爆炸案^③;2022年9月,北溪管道爆炸泄露事件;^④等等。与我国有关的典型事件是2021年6月,“滴滴出行”于美国上市,其带来的风险无法预计;该公司上市第三天,中央网络安全和信息化委员会办公室(“网信办”)下设的中国网络安全审查办公室发布通告:为防范国家数据安全风险,维护国家安全,依据《国家安全法》《网络安全法》,网信办按照《网络安全审查办法》,对其实施网络安全审查;此外它还涉及个人信息安全及隐私保护等问题。其他例子是国内的阿里巴巴、腾讯、百度和京东等大公司利用大数据杀熟,海外的亚马逊、谷歌和 Facebook 可以成为数字经济的领导者,它们拥有大量的用户数据,并且基于算法对数据进行分析,它们的市场表现得以保持在非常高的水平;数据的价值在于,用数据准确地描述事实,用数据发现事物的规律,用数据更好的

^{*} 基金项目:该文系国家社会科学基金重点项目“中国深度参与全球数据知识产权治理的机制、路径与政策研究”(25AZD042)的阶段性研究成果。

作者简介:马忠法(1966-),男,安徽滁州人,法学博士,复旦大学法学院教授、博士生导师,研究方向:国际法学。

预测未来。如此则可能让自己处于竞争优势或垄断地位,进而对市场公平竞争环境及消费者带来负面影响。上述典型事例表明,数据在跨境流动中处理稍微不慎就会带来诸多涉及国家安全、个人隐私保护、公平竞争等法律风险。本文基于现有的研究基础^⑤,试图就数据跨境流动的国际规制及中国因应做些探索。

一、数据跨境流动及其法律风险

(一) 数据跨境流动的界定及其与其他主要相关概念的关系

1. 数据跨境流动含义的解读

本文讨论的“数据”包括个人数据、商业数据、技术数据和公共数据(主要指政府及其他非营利组织依法履行职能含管理或提供公共服务过程中生成、获取的数据)^⑥。由于实践中难以在全球范围内部署服务器,必然存在大量的跨境采集数据情况。就数据跨境流动而言,目前尚无统一的定义。最早的数据跨境流动主要指“个人数据”流动。如1980年,经济合作与发展组织(OECD)在《隐私保护与个人数据跨境流通指引》中首次定义了“跨境数据流动是指个人数据的跨国界移动”。^⑦欧共体(欧盟前身)在其1995年《欧盟数据保护指令》中则将其表述为“数据从一个成员自由地流动到另一成员之现象”;^⑧从1981年的欧洲条约第108号《有关个人数据自动化处理的个人保护公约》规定的字里行间可看出,个人“数据的跨境流动”指的是个人数据不论通过何种方式跨越国界传输并自动处理,或者即使未跨越国界,但被认为用于自动处理的情况。^⑨亚太经合组织(APEC)2015年修订的《APEC隐私框架》指导亚太地区数据跨境自由流动,其相关文件中出现了“跨越国境的数据传输”“跨越国境的信息流动”“信息流动并跨越国境”等不同表述,这些概念在文件中被交替使用。^⑩

从我国相关研究成果看,有学者认为其意指数据跨越国家、地区或国际组织之间的政治边界,并发生数据传输、存储、处理等行为;^⑪数据本身虽未被传输出境,但能够被别国的主体访问也应该被视为数据跨境流动;^⑫或为个人数据跨越国境的访问、收集、流动、处理和存储的全过程;^⑬或指一国数据可跨越物理边界在境外被访问、获取、传输和操作;^⑭等等。网信办2023年《促进和规范数据跨境流动规定》没有对其进行界定,但通过其规范内容,可以看出它应该包括国际贸易与运输、学术合作、跨国生产制造和

市场营销等活动中收集和产生的数据向境外提供,数据处理者在境外收集和产生的个人信息传输至境内处理后向境外提供,数据处理者向境外提供个人信息或其他数据等情形。^⑮有专家在解读该规定时提出,其意指数据处理者向境外提供个人信息等数据;一般将其理解为“数据从一法域被转移至另一法域的行为”或“跨境对存储在计算机中的机器可读数据进行处理”;其具体形式包括两种情形:(1)数据跨境的传输、转移行为;(2)尽管数据尚未跨境,但能够被境外的主体进行访问处理的情形。^⑯网信办在相关出境安全评估指南中作出了类似规定,只是增加了“网信办规定的其他数据出境行为”^⑰。

基于上文分析,本文认为数据跨境流动是指相关主体将数据通过跨越国境(包括物理上的与虚拟的)从一国转移至另一国的行为,含跨越国界对存储在某国相关硬件(含计算机、服务器等)中的机器可读数据进行处理;它主要包括数据出境、入境与过境三种类型,但多数场合下,人们研究的更多的是“数据出境”,本文也不例外,对于“入境”“过境”不予讨论。

2. 数据跨境流动与其他主要相关概念之间的关系

与数据跨境流动关系最为密切的概念主要有“数字贸易”与“数据贸易”。“数字贸易”的字面意思就是指建立在数字技术基础上的贸易。2013年,美国国际贸易委员会(USITC)首次将其定义为“通过互联网提供产品和服务的国内商业和国际贸易总称”,并指出其范围包括数字内容、社交媒体、搜索引擎、其他产品和服务等四类,而将电子商务、互联网金融及其他专业服务依赖网络技术应用商业活动排除在外;^⑱本文将“数字贸易”界定为“基于互联网和互联网技术(或数字化技术)^⑲支撑的国内国际贸易活动之总称”,它以数字产业为依托,通过数字技术来进行实体或数字商品服务交易的国内商业活动和跨境交易活动。有观点认为,它广义上包括通过数字技术订购、交易、支付并进行线下交付的实体商品和服务交易、通过数字技术进行交付服务的交易及涉及数字内容的商品和服务的交易;^⑳而狭义上则仅指后两类。^㉑本文讨论的“数据跨境流动”与第三类数字贸易相关,它包括数字内容服务、数字内容加工处理、数字搜索引擎服务、互联网社交媒体及基于云计算技术的互联网服务等所涉及的数据之跨境流动。

有人将“数据贸易”界定为“以数据为关键生产要

素,以网络为重要载体,以数据资源、数据产品等为贸易标的国际贸易”;^④该定义中,将“数据资源、数据产品等”等作为贸易标的,其中的“数据资源”如何界定?是否包括特定情形下的单个数据?语焉不详。此外,该定义将其界定为一种国际贸易,难道国内就没有“数据贸易”?故本文认为,数据贸易就是以数据及其相关衍生品(含原始数据及其集合如医疗影像、加工后的数据产品如AI训练集与信用评分模型等)为交易客体的贸易,包含国内和国际的数据贸易。

数据跨境流动与国际数据贸易关系密切,但又有本质区别。首先是范围不同,数据跨境流动的范围大于国际数据贸易(数据跨境流动也包括那些并非出于贸易目的的流动,如个人在社交媒体上分享的信息、跨国公司的内部管理数据等,这些数据的流动虽然跨越国界,但并不涉及商业交易),有些数据的流动可能与贸易无关,而数据的国际贸易多涉及数据的跨境流动。流动的本质是行为,即数据跨越国界的传输、存储、处理等活动,是贸易得以进行的前提和基础,而贸易的本质是以数据为标的的国际交易活动,是有特定对价的“经济形态”,是数据流动的重要目的之一(通过交易机制,如数据交易所、数据订阅平台等才能将“数据资源”转化为“可计价、可交付、可复用的商品”)。就二者的表现形式而言,前者有实时传输、API接口、云存储、数据备份等,是数据交易等行为的通道,而后者有数据产品、数据服务、数据许可、数据订阅等,是价值实现的方式。政策焦点方面,前者注重合规性、安全性、主权边界,后者重在价值实现、交易机制、产权确权等。因此,研究数据跨境流动的国际法规制可以将数据贸易的大部分规制内容涵盖于其中。而数字技术是流动和贸易得以完成的依赖方式和物理基础,也是规制所涉及的重要内容。

(二) 数据跨境流动存在的主要法律风险

经济全球化进程的不断加速,“互联网+”、云计算等业务的高速发展,使得数据跨境流动激增;而它在促进一国数字技术创新水平提升和数字经济贸易与产业发展过程中,也带来了诸多法律风险;这些风险意指在数据跨境流动过程中给相关主体因为某种不确定性所可能带来的不利的法律后果。而这些后果通常表现为侵犯个人隐私、影响国家安全或损害国家主权、违反公平竞争法而影响经济发展或经济安全等三个方面。

1. 在数据跨境流动中,侵犯个人隐私自始至终都

是国内法和国际协议规制的主要内容之一,甚至初始时是唯一内容。数据跨境流动与个人信息保护相伴相生,如果缺乏针对“数据跨境自由流动”的合理监管,将无法有效保障个人的隐私安全。其主要风险可归纳为以下五个方面:一是未经授权的数据采集与传输,主要表现为企业在未获得用户明确、充分、有效同意的情况下,将个人信息传输至境外服务器,违反法律规定。如我国《个人信息保护法》关于“知情同意”的规定^⑤等,典型例子是生成式人工智能服务中,用户输入的聊天记录、医疗信息、位置轨迹等敏感数据,可能在未提示用途和范围的前提下被跨境模型训练使用。二是数据泄露与滥用,前者有技术漏洞(如API接口未加密、云存储配置错误)、管理疏漏(如第三方服务商权限过大、缺乏访问控制)及黑客攻击(如中间人攻击、数据拦截)等带来的种种不利后果;后者如个人信息被境外机构用于精准营销、诈骗、身份盗用、用户被“画像”后遭遇算法歧视或价格操控等。三是各国法律规范的差异性带来的风险,不同国家对隐私的定义、保护标准和执法力度差异显著,如欧盟《通用数据保护条例》(GDPR)要求“充分性认定”,而中国要求“安全评估+标准合同”,有些国家对隐私权保护较弱,企业可能选择“监管洼地”存储数据以规避合规义务等。现实中,用户数据一旦出境,可能面临本国管不到、接收国不愿管、平台不主动披露等“三不规制”的尴尬局面。四是数据去标识化失效与再识别风险。由于技术本身的快速发展及在规制它们方面存在局限性,即使采用匿名化或脱敏技术,跨境数据仍可能通过数据拼接、AI还原等方式被重新识别,导致“匿名失败”,特别是医疗、金融、教育等高敏感数据的跨境流动,一旦再识别,后果极其严重。五是数据跨境流动链条复杂,责任主体模糊,如多节点参与:一次跨境流动可能涉及数据控制者、处理者、云服务商、AI模型提供方、境外监管机构等多个主体,责任边界难以厘清;此外追责困难:如发生泄露,用户难以确定责任方,维权成本高,司法救济路径复杂。

简言之,数据跨境流动增加了数据泄露的风险,可能导致个人信息和企业机密信息的泄露。不同国家的隐私保护法规差异可能导致企业在数据跨境流动中难以平衡合规与业务需求。

2. 威胁国家安全或主权。数据跨境流动在促进全球数字经济发展的同时,也带来了日益严峻的国家

安全风险;^[6]这方面的风险主要体现在以下五个方面:一是涉及国家安全的核心数据与敏感信息泄露,如涉及国家地理、军事、能源、交通、金融等核心领域的核心数据一旦出境,可能被境外政府、机构或敌对势力获取,用于情报分析、战略侦察甚至网络攻击。2021年“滴滴出行”在未经网信办审核背景下,在美国上市,就是典型例子:滴滴因违规将涉及地理轨迹、用户行为等敏感数据跨境传输至美国,^[7]被处以80.26亿元罚款,并启动国家安全审查;另一案例是2018年华大基因等6家机构因违规向境外提供中国人遗传基因数据,被科技部处罚。二是数据主权受到威胁。数据主权是国家主权在数字空间的延伸,涵盖数据控制权、立法权与管辖权等。若关键数据长期由境外云服务商或算法平台控制,将导致本国在数字治理中丧失主导权。如海南自贸港、跨境电商综合试验区等地,虽鼓励数据开放,但也面临“数据自由化”与“主权安全”之间的制度张力与平衡。三是跨境数据被用于战略遏制与技术脱钩。美国等国家已将某些数据的流动纳入国家安全战略,通过《出口管制条例》《外国投资风险评估现代化法案》等限制中国获取AI训练数据、芯片设计数据等关键资源,推动“AI脱钩”;它们促使数据地缘政治工具化,对数据跨境流动采取双重标准:一方面要求中国开放市场,另一方面限制中国获取其相关数据,形成“数据霸权”格局。四是关键基础设施遭渗透与攻击。跨境数据流动扩展了攻击面,境外主体可通过合法或非法手段访问能源、交通、金融等关键系统的数据接口,实施远程操控、数据篡改或系统瘫痪。如2023年某跨境电商平台数据库泄露,数百万中国公民身份证信息被境外黑客获取,威胁国家身份认证体系。五是法律真空与事后监管失效。如当前我国对数据出境的监管主要依赖“事前安全评估”,但对数据出境后的使用、存储、流转缺乏持续追踪机制,导致“事前合规、事后失控”。

3.对经济发展带来的挑战。数据跨境流动对经济发展带来的风险主要有:一是增加经济成本。许多国家为了保护数据安全和隐私,要求数据存储在本地服务器中(数据本地化要求);这种数据本地化政策会显著增加企业的运营成本。数据表明,如果欧盟的跨境数据流动受到本地存储等严重影响或扭曲,可致其国内生产总值(GDP)下降0.8%至1.3%不等,其美国制造业出口可能会减少约11%;^[14]数据本地化

的立法等使以下六国的GDP影响均有所下降:巴西(-0.2%)、中国(-1.1%)、印度(-0.1%)、印度尼西亚(-0.5%)、韩国(0.4%)和越南(-1.7%)。^[11]而在美国,减少跨境数据流动的障碍将使其GDP增长0.1%至0.3%。^[12]^{P14}由于不同国家的数据保护法规存在差异,企业需要投入大量资源来满足这些法规要求,也增加了合规成本。二是市场竞争受限。数据跨境流动的限制可能导致企业难以进入国际市场,在市场准入方面形成障碍,如一些国家的数据保护法规要求企业必须在本地设立数据中心,这增加了企业市场准入门槛,尤其是中小企业受影响最大。大数据公司由于在垄断方面具有优势地位,利用这种地位损害小企业或消费者权益,进而影响经济的健康、良性发展。数据无形及零成本复制的特征结合互联网传播便捷等极易导致集中和垄断,会强化相关大企业的市场力量及其优势,加上互联网企业在资本运作下的频繁并购,寡头垄断的市场格局很容易产生。数据垄断企业为了保护自身利益,可能会过度收集并囤积数据,减少共享,阻碍数据合理流动和共享。此外,它们还借助垄断优势进行价格歧视,抬高整体价格,降低消费者剩余和总福利。^[13]这既损害了消费者福利,还挤压了竞争对手生存空间,破坏了市场竞争规则,阻碍了数据合理流动和共享。三是创新和经济增长受阻。数据跨境流动的限制会导致创新动力不足,阻碍新技术的发展,如物联网、AI和云计算等技术发展依赖无障碍的数据流动;它也会放缓经济增长,数据流动障碍会破坏全球价值链的分解和离岸服务枢纽的创建,从而对经济增长产生负面影响。四是国际贸易和投资受阻,贸易壁垒增加。数据跨境流动的限制被视为一种新的贸易壁垒,可能影响国际贸易和投资。数据本地化要求是数字通信领域的主要贸易障碍;它可能导致出口下降,如由于竞争力的直接丧失,中国和印度尼西亚的出口也下降了1.7%。^[11]本地化存储带来的数据自由流动的障碍对内部投资也会带来不利影响,如对以下国家或地区的影响是:巴西(-4.2%)、中国(-1.8%)、欧盟(-3.9%)、印度(-1.4%)、印度尼西亚(-2.3%)、韩国(-0.5%)和越南(-3.1%)。^[11]此外,还会使特定领域的国际经济合作受阻,影响全球数字经济的发展,对特定行业带来负面影响,如在金融服务行业,限制数据跨境流动可能影响该行业的跨境业务,如跨境支付、金融数据共享等;在医疗行业,

医疗数据跨境流动的限制可能影响远程医疗和跨境医疗研究合作,阻碍医疗资源的优化配置。

二、调整数据跨境流动的主要多边条约规制及核心内容

为减少或规避数据跨境流动带来的法律风险,上世纪80年代初,国际社会试图通过一系列规则在适当条件下允许数据自由流动以促进经济发展。当下全球范围内尚未形成全面统一的数据跨境流动的国际规则体系,各国规制数据跨境流动的手段主要是将相关规则嵌入各种多边或双边自由贸易协议中。有研究表明,全球已有180多个贸易协议增设了包括数据跨境流动在内的数字贸易规则专门章节或专门条款。^[14]调整跨境数据流动的国际规范,形式上区域性多边及双边自由贸易协议规范的较多,而全球性多边涉及较少;内容上,软法规范的,较多,硬法规定的,较少。调整数据跨境流动多边区域性的条约中,代表性的有《全面进步的跨太平洋伙伴关系协议》(CPTPP)、《美国-墨西哥-加拿大协定》(USMCA)、《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)、《新加坡-智利-新西兰数字经济合作协议》(DEPA);此外便是被定位为“纯数字”双边贸易协议,即《新加坡-澳大利亚数字经济协定》(SADEA)。此外,还有一些软法性质的国际法文件,如联合国当下正在制定的《全球数字协议》(Global Digital Compact)、OECD的《关于保护隐私和个人数据跨境流动指南》^⑧及《隐私和跨境个人数据流动保护指南》^⑨,APEC的《2015年隐私框架》^⑩及《跨境隐私规则体系》(CPBR)^⑪;等等。

(一) 全球性多边条约及其规制的核心内容

目前全球层面的相关规范主要体现在WTO框架下1995年生效的多边协议《服务贸易总协定》(GATS)及1997年生效的诸边协议《信息技术协定》(ITA,2015年修正)等中。GATS规定隐含支持数据自由流动,但GATS第十四条一般性例外(要求“保护与个人资料的处理和散播有关的个人隐私以及保护个人记录和账户秘密”)和安全例外(不得解释为“阻止任何成员为保护其基本安全利益而有必要采取的行动”),使跨境数据自由流动具有前提条件,给各国限制数据跨境流动留出了政策空间。2015年修正后的ITA扩大了产品涵盖范围,旨在逐步将信息技术产品的关税削减至零,是与数据相关的重要国际协

定,82个成员国代表了全球97%的信息技术产品出口额,将产品范围扩大至200多个。梳理上述WTO主要协定,发现GATS电信附件第5条“公共电信传输网和服务的进入和使用”规定,与跨境数据流动相关,但总体而言,该协议主要涉及信息技术产品及相关服务,而较少涉及数据跨境流动本身。GATS未将数据跨境流动纳入调整的范围之内,导致了适用上的不确定性与困难,而目前只能寄希望于在争端发生时采取逐案分析的方式,以确定跨境数据流动应当适用的具体协定及该协定项下的具体条款;^[14]云计算、社交平台等新兴数据服务缺少明确归类,专家组在审查数据限制措施是否违反GATS义务时,只能逐案分析,无统一适用标准。2017年,71个WTO成员提出诸边电子商务联合声明倡议(JSI),2019年提出制定《电子商务协议》,经过5年的谈判,2024年7月26日,91个WTO成员^[14]就该协议已形成含38个条款的稳定文本,但就数据跨境自由流动而言,未要求成员必须允许自由跨境流动,只是其第25条就个人数据规定“本协议不妨碍缔约方采取或维持保护个人数据和隐私的措施,包括跨境数据传输,只要该缔约方法律提供了适用于数据传输的通用保护机制。”^[14]

简而言之,现有的WTO规定不强制数据自由流动,不禁止数据本地化,例外适用空间范围较大,涵盖隐私、国家安全、公共政策等。显然,在WTO框架下,数据跨境流动的适用标准仍然不明确。

(二) 调整数据跨境流动的主要区域性多边或双边条约规制的核心内容

从目前达成的各种涉及数据跨境流动的协定内容来看,它们主要包括:确保数据自由流动和禁止数据本地化要求等方面的规则;禁止影响外国数字产品的关税和歧视性政策,以及防止不公平地要求转移来源代码或敏感算法给政府等。但上述这些规定是松散的,条约和条约之间缺少系统的协调性。本文以成员、影响力、内容的全面性为衡量基准,选择了前述五个关键的涉及数据跨境的贸易协定,即CPTPP、USMCA、RCEP、DEPA及SADEA^⑫进行简要分析。

CPTPP是日、澳、加、墨、新西兰、新加坡、文、智、马来西亚、秘、越和英12国间的自由贸易协议,脱胎于《跨太平洋伙伴关系协议》(TPP),于2018年12月30日在前六个经济体中首次生效,其余后续加入。该协议的电子商务章节制定了促进数字贸易的规则,

允许参与成员优先进入彼此的市场,包括促进数据流动、保护隐私和消费者权益以及知识产权的措施。2020 年 7 月 1 日生效的 USMCA 是美、墨、加之间的自由贸易协定,取代北美自由贸易协定(NAFTA);它包括一个关于数字贸易的章节,该章节也是建立在 TPP 规定之上,包括禁止数字产品关税,保护数据流动、隐私和知识产权,并促进网络安全合作等。DEPA 于 2020 年 6 月 12 日在智利、新西兰和新加坡之间签署;作为首个专门规范数字贸易的、开放的诸边协定,旨在通过创造数字化机会来提高国家之间的互操作性,加强数字贸易合作,促进互联互通;它重点包括数字产品处理、数据问题、新兴技术、数字包容和中小企业合作等议题。其所涉关键问题主要有电子设备使用、国民待遇和数字产品的非歧视性,促进跨境业务的文件编制(包括电子发票和促进电子支付)、个人资料保护、网络安全、在线消费者保护(包括致力于消除不请自来的广告信息含垃圾邮件的承诺)、保护安全数字身份、实施人工智能的道德治理框架、自由数据流及通过确保访问开放的互联网来解决数字鸿

沟和数字包容性问题。它还包括承诺分享推广和开发新物流技术的最佳实践。其数字产品方法保持了早期协议中关于暂停对电子商务征收关税的承诺。它还增加了一个加密标准,禁止各国在进口加密产品时要求密钥或访问代码。它通过禁止各方强制数字产品或服务提供商在其领土内安装服务器以使其能够运行来维持避免强制定位数据的承诺。RCEP 由东南亚国家联盟十国发起,中、日、韩、澳、新西兰等五国后来共同参加,于 2020 年 11 月 15 日签订;在数字贸易领域,虽然它沿用了 TPP 的大部分框架,但更大程度地保留国家调节作用。RCEP 涉及数据领域规则的内容主要含有数据传输、计算设施要求、线上消费者保护、个人信息保护、核心代码披露、知识产权、开放政府数据、网络安全、数据关税和数据垄断等。SADEA 于 2020 年 8 月 6 日签署,是在 CPTPP 和新加坡-澳大利亚自由贸易协定的基础上设置的一系列的有关数字经济的贸易规则;除了正文外,它还包括七个谅解备忘录,即人工智能、数据创新、数字身份、个人信息保护、电子发票、贸易便利化和农产品电子认证。

区域性协议中关于数据跨境流动的规范与异同

主要条款	CPTPP	USMCA	DEPA	SADEA	RCEP
章节	第十四章 电子商务	第十九章 数字贸易	第九章 数字经济	第十四章 数字经济	第十二章 电子商务
适用范围	适用于缔约方采取或维持的以电子方式影响贸易的措施。	同 CPTPP	适用于一方采取或维持的在数字经济领域影响贸易的措施。	适用于一缔约方采取或维持的以电子方式影响贸易或促进贸易的措施。	适用于一方采取或维持的影响电子商务的措施。
目的	通过电子商务促进经济增长和贸易机会,鼓励保护消费者和个人信息,加强在电子商务全球问题上的合作。	通过消除电子方式进行贸易的不合理障碍,为投资者和公司提供法律确定性,并确保为消费者提供安全的在线环境。	建立新的方法和合作,促进不同制度之间的互操作性,并解决数字化带来的新问题。	创建一个无缝的数字交易环境。	采用数字化解决方案,提高电子商务用户的信任度和信心,加强成员国之间在电子商务发展方面的合作。
数据传输	促进跨境数据自由流动,最大限度地减少数据本地要求。但为了实现合法的公共政策目的,成员保留维护和修改与数据流相关的法规的能力。	同 CPTPP	同 CPTPP	同 CPTPP	同 CPTPP,但是成员确认实施此类合法公共政策背后的必要性应由实施方决定。
计算设施要求	除为实现合法的公共政策目的外,成员不得强制商业主体使用本地设施,不应妨碍公司提供云计算和数据存储服务。	各方不得强制商业主体使用本地设施,成员不会妨碍公司提供云计算和数据存储服务。	同 CPTPP	同 CPTPP	同 CPTPP 但是成员确认实施此类合法公共政策背后的必要性应由实施方决定。
线上消费者保护	各方承诺会保护消费者隐私,实施消费者保护并抵制垃圾邮件。	同 CPTPP	各方应通过或维持法律或法规,为使用电子商务的消费者提供保护,使其免受因欺诈性和误导性的做法而造成的损害或潜在的损害。	双方承诺合作创建和促进安全在线环境;各方应通过法律法规,为使用电子商务的消费者提供保护,使其免受因欺诈性和误导性做法而造成的损害或潜在损害。	各方应通过或维持法律或法规,为使用电子商务的消费者提供保护,使其免受因欺诈性和误导性的做法而造成的损害或潜在的损害。

主要条款	CPTPP	USMCA	DEPA	SADEA	RCEP
个人信息保护	各方承诺基于相关国际指引的基础上对个人信息进行保护。	同 CPTPP。在国际指引上提出引用 APEC 的 CBPR 隐私政策和 OECD 的指引。	同 CPTPP,但是对个人信息保护的要求更加细化。	同 CPTPP。在国际指引上提出引用 APEC 的 CBPR 隐私政策和 OECD 的指引。	同 CPTPP
核心代码披露	各方在寻求引进或分发软件时不会要求访问专有软件源代码。	对政府要求披露源代码、算法的情形有所限制。	N/A	同 CPTPP,但是对政府要求披露源代码、算法的情形有所限制。	N/A
知识产权	适用国民待遇	适用国民待遇	适用国民待遇	适用国民待遇	适用国民待遇
开放政府数据	N/A	在向公众提供包括数据在内的政府信息的范围内,缔约方应努力确保该信息作为开放数据提供。	同 USMCA	同 USMCA	N/A
网络安全	各方认识到通过国家计算机应急小组的工作开展网络安全合作的重要性	建立各自负责网络安全事件响应的国家实体的能力;和同意关注基于风险的方法而不是规范性监管	各方认识到需要建立负责网络安全的部门,合作识别和减轻威胁并培养人才的重要性	同 DEPA	各方认识到需要建立负责网络安全的部门,以及在现有合作机制上合作的重要性。
海关关税	1、禁止电子传输关税 2、保留征收内部税收的权利。	同 CPTPP	同 CPTPP	同 CPTPP	在 CPTPP 的基础上,保留根据 WTO 电子商务提案对关税安排作出修改的权利。
数据垄断	禁止缔约方以“必须本地存储/处理”为条件限制企业进入市场,除非符合“合法公共政策且不过度限制贸易”;禁止将“在本地设立计算设施”作为营业前置条件;缔约方给予境外数字产品的待遇不得低于同类本土产品。各方须有效执行本国竞争法及政策;建立竞争主管机构;程序公正、透明、非歧视;鼓励各方在跨境垄断案件上信息共享与执法合作。	同 CPTPP,但计算设施方面无例外条款(不同之处,删除了“考虑监管需要”或“公共安全例外”的表述);对“垄断”态度:市场优先,限制监管。	基本同 CPTPP,但数据流动例外适用较为宽松(仅为公共政策例外),竞争政策合作方面专设数字经济执法合作;对垄断态度是“弹性监管,强调竞争”,中小企业保护有专章扶持。	数据跨境流动例外同 DEPA;源代码/算法强制披露方面允许“竞争执法例外”;竞争执法合作方面含专设 MOU+技术标准;中小企业保护方面通过技术标准+执法合作间接保护。把“竞争政策例外+执法合作+技术标准”嵌入数字贸易规则,兼顾数据自由流动及为中小国家和本土企业预留反垄断政策空间。	大体上同 CPTPP,但特色有:数据本地化禁止,原则禁止+公共政策/安全例外;竞争政策例外方面,明确纳入公共政策;安全例外可以自裁决但不可仲裁;发展中成员弹性规定,有过渡期、技术援助(“东亚模式”)

三、数据跨境流动国际法规制的主要不足及其发展趋势

针对上述风险,数据跨境流动国际法规制的核心问题,实质上主要有个人隐私保护、安全与发展利益等在全球数字空间中的再平衡等,现有的国际法规制在防范这些风险方面显然存在不足,本目就此进行分析和探讨,并就发展趋势做一分析。

(一) 数据跨境流动国际法规制的主要不足

1. 碎片化现象严重

国际上不仅对数据跨境流动的概念尚未形成统一的看法,对数据跨境流动治理或规制也并未形成全球性规制体系,尤其在硬法方法。OECD、APEC、二十国集团(G20)和WTO等国际机制,成为参与全球跨境数据流动治理的主要多边机制。美国和欧盟作为两大独立法域,正积极开展跨境数据流动治理

和规制协调。^[17] 囿于各方立场显著分歧,各国目前在数据跨境流动规范方面没有形成一致认知,各国基于本国国情及实际发展水平,对此态度不一:数据强国基于自己的优势,希望数据自由流动,而数据弱国或数据提供者,则期待数据本地存储或遵循本地化原则。当前WTO在数据跨境流动规则制定方面仍未取得突破性进展,尚未建立起专门的数据跨境流动协议,究其原因,WTO在制定适应全球新形势的数字贸易规则方面相对滞后,突出表现为未能明确界定数据流动的性质。当数据作为服务进行贸易时,其货物与服务属性之间的界限难以准确界定。尽管GATS依据《服务部门分类表》对全球服务领域进行了划分,但该分类并未将新兴的数据服务纳入其中,这意味着数据流动尚未被认定为GATS的服务类型。即便是初步达成的《电子商务协议》与现有的几项双边和区域涉及数据跨境流动的协议不同,它没有

要求数据跨境自由流动的条款。

CPTPP、RCEP、DEPA 等区域性自由贸易协定虽均设数据流动专章,但相互间存在“例外口径-争端解决-执行机制”等方面的差异,碎片化明显。国际法规制的挑战有法律框架的碎片化,^[13]不同国家和地区的法规差异导致企业合规成本增加;数据主权与全球化之间的张力,各国对数据主权的强调与数据自由流动的需求之间存在冲突;人工智能、区块链等新兴技术的跨境应用对传统数据治理模式提出了新挑战。国际社会在反垄断领域缺少相应的协调,无统一的条约规制跨国间的数据垄断。

各大经济体之间就数据跨境流动规制也意见不一,有学者将现有的规制政策归纳为五大合作圈,各合作圈也有交叉、合作,^[14]但碎片化的现象十分明显。如美国,其贸易政策优先考虑数据的自由流动和数字贸易带来的机会;而且随着时代变化,其规制也在做适当调整,早期主张数据跨境自由流动的承诺(集中体现于 TPP 中),后日渐向“自由与安全兼顾”转变,有学者称之为“限定型自由流动”。^[15]美国国际贸易频繁,实力雄厚的大型跨国公司众多,信息技术水平独占鳌头;积极倡导电子商务的自由发展,谨慎立法,对个人信息保护采取较为弱化的政策更符合美国利益。^[16]CPTPP、USMCA 等协定虽倡导数据自由流动,但允许“合法公共政策例外”,导致规则解释空间过大,实际约束力有限。^[17]欧盟以 GDPR “充分性决定+标准合同条款”为核心,辅之以“适足保障”与“额外措施”模板,强调人权与隐私保护。个人数据跨境传输的前提是符合某些特定要求或者接受方所在的司法辖区被欧盟所认可;跨境传输个人数据时,接收国必须具备与欧盟相当的数据保护水平,或通过标准合同条款(SCC)、约束性企业规则(BCR)等机制确保数据安全。俄罗斯、印度等国家也制定了严格的本地数据保护法规,要求跨境数据传输必须符合特定条件,强调数据本地化,要求关键数据必须在境内存储或处理。APEC 通过跨境隐私规则(CBPR)系统,推动数据跨境流动的互操作性,允许成员国在满足一定条件后进行数据传输。

在数字时代,跨境数据流动已成为全球经济的基石,支撑着从国际贸易和金融到社交媒体和云计算的一切。然而,随着数据越来越多地穿越多个司法管辖区,它遇到了一个复杂的法律框架网络,这些框架管理着数据的传输、使用和保护;它们因地区而异,反映了不同的国家优先事项、对隐私的文化态度和技术发展水平。欧盟 GDPR 就是突出之例,为全

球数据保护设定了高标准。相比之下,其他地区,如美国、中国和亚太经济合作组织的跨境隐私规则体系成员国,已经制定了自己的监管方法,导致全球格局支离破碎。这种碎片化给寻求国际化运营的组织带来了重大挑战,因为它们必须应对可能阻碍数据流动和创新的相互冲突的法规和合规要求。探索国家数据保护法律多样性带来的法律、技术和外交挑战,包括数据主权、跨国组织合规负担以及国家法规之间的冲突等问题。有学者基于现有规范的内容分析,从单边机制冲突、区域协定割裂和排他性数据圈三个维度分析碎片化,即前者指某些国家的国内法规定与他国的规定产生冲突(如美国《澄清境外数据合法使用法》(《云法案》)与大多数国家的数据出境法律形成直接冲突等);中者指“区域协议的分化”,即在数据跨境流动领域,不同的区域或国家集团通过制定各自的数据治理规则和机制,形成相互独立的制度体系;其核心在于规则差异和机制竞争,反映不同区域在数据主权、隐私保护、经济利益等方面的战略分歧;后者指大国或国际组织试图利用自己的规则主导全球数据治理话语权,最终形成互不兼容的排他性数据圈。^[22]这种划分方法未必准确,但碎片化使得跨国企业需同时应对多套标准,中小企业尤其难以负担合规成本。^{[23] P6}

国际规则碎片化易导致“监管套利”(避重就轻)及阻碍数据合理流通。规则冲突使不少国家通过本地化数据立法强化对数据资源掌控,截至 2023 年,全球有 40 个经济体实施 96 项数据本地化措施,且 2/3 以上不仅要求数据本地化存储,还禁止数据跨境流动,形成“数据孤岛”。^[24]碎片化规则加剧了发展中国家的困境,跨国科技公司通过云服务与算法平台输出技术框架,也可能侵蚀相关国家的数字主权。企业可能利用监管差异进行“制度套利”,将数据转移至监管宽松国家,规避本国审查。此外,各国个人数据保护标准也存在差异。这种割裂的数据治理体系阻碍着 AI 所需的全球数据流通。

2. 双边或区域性协议难挑大梁

应对数据跨境流动治理的挑战至关重要,但现有的双边和区域性多边协议,难以有效完成这样的任务,它们对协调不同经济体之间的数据跨境流动之规制力不从心。前者如欧盟-美国数据隐私框架(之前是隐私盾协议),代表了弥合监管差距和促进不同法律制度之间数据流动的尝试;然而,这些协议往往受到法律挑战和政治审查,如 2020 年欧洲法院宣布《隐私护盾》无效所示。后者如 CPTPP、RCEP、

DEPA 等协议中规定的跨境数据流动的规范只在特定区域的成员之间发挥作用,且不同协议之间自身也存在一些冲突或有待协调之处。区域合作在短期内提供了一种更务实的方法。例如,APEC 的 CBPR 系统为区域协调提供了一个模型,该模型在尊重当地隐私规范的同时实现了跨境数据流动。然而仅靠区域性或双边自由贸易框架不足以解决数字数据的全球性问题。此类协议的局限性表明,国际社会需要更全面、更有弹性的框架。越来越多的人主张建立一个全球数据保护框架,使关键原则标准化,同时允许区域差异。然而,鉴于不同文化和政治制度对隐私的看法和监管存在根深蒂固的差异,就数据保护标准达成全球共识是一项艰巨的任务。迫切需要更广泛的国际合作,如通过 WTO 或联合国等现有国际机构,制定更具包容性和全面的解决方案。

3. 新兴技术的影响难以应对

AI 大模型、大数据、量子加密和区块链等技术的快速发展、迭代周期短给现有的数据传输法律框架带来了新的挑战,数据跨境立法严重滞后,导致“技术已商用、规则仍空白”的脱节现象普遍出现。^[23] 这些技术颠覆传统的隐私和数据保护观念,因此有必要重新评估法律标准。如 AI 依赖大量数据,这些数据通常是跨境收集和处理的,这引发了人们对同意、数据最小化和问责制的担忧,而现有法规可能无法充分解决这些问题。区块链技术具有去中心化的性质,给数据治理带来了独特的挑战。将传统的法律框架应用于基于区块链等新技术体系或系统中面对着诸多困难,因为在这种系统中,数据可能同时分布在多个司法管辖区,使合规和执行问题复杂化。缺乏隐私增强技术国际标准让隐私保护困难重重。

人工智能、大数据和区块链等新兴技术影响着数据跨境流动的治理,并挑战了现有的法律框架。为应对新技术之下数据跨境流动的规制,我们需要评估现有的国际合作和协议在多大程度上成功地协调了数据保护标准,促进了跨境数据流动,同时也有效地保护了隐私并促进了经济增长;同时分析还存在哪些不足,进而针对不足,提出适当建议,强调需要适应性法律框架和协作方法,加强全球数据治理,以应对数字时代跨境数据流动的动态挑战。此外,调整全球数据流动法律规范的零散性、滞后性给新技术语境下的数据跨境治理也带来了重大挑战,跨国组织在遵守不同监管要求方面也面临重重困难。新技术发展下的相互冲突的数据保护标准的法律和操作复杂性也对全球数据跨境流动等带来负面影

响。技术标准割裂使 APEC 的 CBPR 体系与 GDPR 互认困难,区块链等新技术应用尚未纳入国际规则框架。技术标准碎片化抬高合规成本。各国对加密算法、匿名化技术、可解释 AI 等要求各异。企业为同时满足欧盟 GDPR、美国《云法案》、中国《数据安全法》三套技术标准,往往需要建设多条技术路线,导致投资与运营成本指数级上升。显然,这种不统一不利于依赖于统一或兼容的技术标准、通信协议和数据格式的跨境数据流动。差异化的技术标准导致数据传输和处理难以兼容,由此可能降低数据流动效率;不同的加密算法和密钥管理标准增加了数据安全保护的复杂性;相异的数据脱敏和匿名化标准增加数据合规风险;数据存储格式和数据库系统不兼容增加数据迁移与再加工难度;差异化的数据处理工具和平台标准,影响数据分析、利用和运营的效率。由于各国数据质量评估标准不一致,跨境流动数据的质量难以得到有效保证,在数据处理过程中可能会出现数据失真或损失的情况。^[24] 去中心化架构瓦解传统“属地管辖”逻辑,区块链、分布式存储、边缘计算把数据切分成多副本,分散在多个司法辖区,难以确定“数据处理地”或“控制者所在地”,传统的数据出境评估、行政许可无法落地。^[27]

在数据主权与技术的关系方面,技术发展水平较高的国家可以依赖技术保护自己的敏感数据与国家利益,给数据跨境传输带来了另一层复杂性。各国政府如何出于对隐私、安全和经济控制的担忧,越来越多地对其境内产生的数据主张主权,技术是依赖。数据本地化的趋势,即各国要求数据在其境内存储或处理,挑战了互联网的开放性,并使数据方面的国际合作复杂化。技术语境下的数据主权冲突带来守法悖论,如美国通过《云法案》要求在美注册企业提供全球数据,欧盟 GDPR 第 48 条又禁止为外国法院裁决直接传输数据;中国《数据安全法》第 36 条再要求“非经主管机关批准不得向外国司法或执法机构提供数据”。由此给相关企业合规带来挑战。实时数据流动使传统“事前审批”失灵,如物联网、车联网、全球内容分发网络、金融高频交易场景下,数据以毫秒级流动。如果仍采用逐笔事前安全评估,将阻断业务实时性,导致监管与效率不可兼得。生成式 AI 放大了“数据管辖权漂移”,大模型训练需要汇聚全球语料,所涉及的参数规模超千亿,训练过程跨云、跨区、跨法域流动。一旦模型输出涉及敏感内容,无法追溯是哪一司法辖区的原始数据所致,给事后问责带来真空。匿名化与再识别技术赛跑,差分隐

私、联邦学习等技术尚无法 100% 避免重识别风险;而 AI 反匿名技术却不断突破,导致“技术-法律”攻防失衡,令现有跨境传输豁免条款随时可能失效。

此外,现有的相关规制还存效力层级较为低下、执行机制较弱等不足。现有数据跨境流动规则大量存在于各种软法、指南和自律规范或标准之中,诸多规范缺乏强制执行力;即便是 DEPA、RCEP 等也主要依赖国家间磋商或贸易报复,企业无法直接援引;而且,国际多边执法合作也极度缺失,使得数据调取仍依赖双边司法协助条约,平均耗时常在 10 个月以上。针对不同规范之间存在的冲突,也无相应的解决机制,如美国《云法案》与欧盟 GDPR 第 48 条直接冲突,却无多边调处机制。发展中国家话语权在该领域也存在严重不足,规则制定权集中在美欧,CBPR 2.0、OECD 指南等“俱乐部式”标准将多数中小经济体排除在外,数据红利分配失衡,等等。这些都对数据跨境流动的国际法规制提出了要求。

(二) 数据跨境流动国际法规制的主要发展趋势

随着技术发展和各国交流日益加深,数据本身的含义也在不断拓展,由原先的个人数据,逐渐拓展到今天还包括商业数据、公共数据等。有学者认为当下的数据跨境流动的国际法规制的态势基本上是“原则+例外”,即鼓励数据自由流动为基本原则,针对特殊情形自由流动受到限制;^[21]从当下争议的核心看,这种态势仍会持续,无非就是对数据进行较为精准的分类,细化相关标准,在监管方面注重例外情形(尤其一般例外与安全例外的详细规定)。数据跨境流动是一个不断发展且复杂的动态领域,需要各国在国家安全、保护隐私、防止垄断和促进数据流动之间找到平衡,涉及法律、技术和政策等多方面挑战;前文讨论的基本界定不仅现在这样,将来还会如此,只是在限制方面如何更为精准,以真正实现数据的价值。各国在保护个人隐私和国家安全的同时,也在努力促进数据的自由流动,以推动数字经济的发展。未来,国际法规制可能会朝着以下五个方向发展:(1) 加强国际合作,通过双边或多边协议来协调数据跨境流动的规则,促进数据保护标准的协调。(2) 完善技术中立法规,制定更为灵活、有效和有针对性的规则技术中立的法规,制定更灵活、技术中立的法规,以应对新兴技术带来的挑战。(3) 促进数据治理的全球化,推动全球范围内的数据治理框架,平衡隐私保护与经济发展。(4) 明确或限定数据本地化,一些国家要求特定类型的数据必须存储在本国境内,以保障数据安全。(5) 推行负面清单制度,中

国等国家正在探索建立数据跨境流动的负面清单制度将得以广泛实施,以简化合规流程。

简言之,促进自由流动为数据跨境流动的基本要求和趋势,但成员国可基于隐私保护、国家安全等理由限制数据出境,只要提供如“标准合同条款”“认证机制”等合规工具,限制即视为合理,不过限制措施不得构成任意歧视或对贸易的变相限制。通过诸边谈判逐步推进,但短期内难达成强制性统一规则。

四、数据跨境流动国际法规制的中国应对

全球缺乏统一的国际数据治理框架导致各国在数据跨境流动规制上难以达成共识。有学者认为,我国相关的国内规制措施已经与国际接轨。^[21]这种观点未必很准确,因为很多国际规则尚未成熟,还在探讨之中;因此,问题不在于接不接轨,而在于如何探寻出数据跨境流动中的规律性问题并由中国引领相关规则的制定。中国该方面规制是以“安全可控风险防范”为底线并兼顾发展等为原则,通过重要数据评估、个人信息多元化出境路径、自贸区试点豁免等机制,逐步构建“精准管控+有序流动”的法治框架,在做到安全和个人隐私保护前提下,促进经济发展。未来需进一步明确数据分类、优化评估标准,以增强国际互信与企业合规确定性。中国正在努力构建的“宽进严出、一体多层”^[22]的数据跨境治理体系,既参与国际规则制定,又防范外部制度渗透。它是我国在数字经济全球化背景下实现安全与发展的系统性关键制度创新,以风险可控为前提,以发展需求为导向,以技术治理为支撑,以多元协同为保障。它既回应国际规则竞争,也兼顾国内治理需求,为我国数字经济高质量发展提供了制度保障,标志着中国正从数据跨境治理的“制度跟随者”转向“规则引领者”。

(一) 国内层面:完善国内相关法律制度,为参与或引领国际规则创造积极条件

国际法的本质主要是各国间的意志妥协,但这种妥协须建立在符合某一特定领域发展规律或本质之上。国际法某一制度的形成也是在一国法律实践基础上慢慢形成和发展起来的:国内经验的成功,影响到周边国家或地区,进而被它们所接受,随后,再在更多国家推广,在更大范围内被接受。

建立和完善我国相关制度,为该领域的国际规制奠定条件,是需要优先考虑的问题。我们需在大量的数据跨境流动活动基础上归纳出其基本规律,并遵循该规律制定出法律规则,以更好地促进全球数字贸易的发展。我们应依不同数据类型体现的国

家安全、公共利益、数据主体利益的不同对数据流动进行分类规制,并在法律层面明晰各类数据的范围。^[28]同时,落实数据监管的责任主体,鼓励行业协会、专业服务机构参与安全评估。中国已构建以《网络安全法》(2017)^[29]《数据安全法》(2021)^[30]和《个人信息保护法》(2021)^[31]三法为基础的数据跨境流动的基础法,结合《民法典》^[32]、《国家安全法》《对外关系法》《反外国制裁法》等相关法律,对数据跨境流动已作出了相对体系化的规定,对数据跨境传输设定了严格限制,要求数据存储和处理在境内进行,除非满足特定条件。《数据出境安全评估办法》要求关键信息基础设施(CII)运营者向境外提供重要数据时,必须进行安全评估。此外,中国政府高度重视数据跨境流动的政策制定和战略支撑。目前制定的有关数据跨境的政策有《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(“数据二十条”),就是为了在数据领域深化开放合作,以与各国实现互利共赢。它要求我国积极参与数据跨境流动国际规则制定,探索加入区域性国际数据跨境流动制度安排;推动数据跨境流动双边多边协商,推进建立互利互惠的规则等制度安排。中国主要数据存储本地化原则,以《数据安全法》《个人信息保护法》为框架,采用“安全评估+标准合同+认证”三元路径,并坚持“公对公”境外执法原则。我国在构建数据跨境流动规则过程中应处理好国家安全、以个人隐私为核心的相关数据主体权益、经济贸易发展需要等之间的平衡关系。在数字技术发展与全球化深入同步背景下,数据跨境流动是不可避免的,而对其自由流动的限制和监管也是必不可少的。我国目前无专门法律来规范并推动数据跨境流动的有序进行,既不利于我国数字贸易的全球化开展,也不利于国家安全和个人隐私等的有效维护。^[28]为此,可从以下三方面努力:

首先是确保法律条文本身的精准、精炼,协调相关法律之间的关系,避免重复及相互冲突。对于前一现象,如《民法典》关于“个人信息保护”的规定,就有重复,其第111条规定“自然人的个人信息受法律保护”与第1034条第一款规定的一模一样,在同一个法律中,这样规定似无必要。对于后一现象,如对于个人信息^[33]的界定,目前《民法典》第1034条第2款、《个人信息保护法》与《网络安全法》规定就不完全一致。前者规定“个人信息是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的各种信息,”并列出了包括自然人的姓名等9种信息;中者规定它是以电子或者其他方式记录的

与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息,不包括匿名化处理后的信息;^[34]而后者规定它是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别自然人个人身份的各种信息,后面用了“包括但不限于”之表达列举了6种信息。^[35]三种界定各有所长,但前者更为全面,中者更为精炼,而后者似乎存在明显不足。我们的建议是将三者进行融合后放到《民法典》中,即吸纳中者的定义和前者的外延,在后两者中不再界定“个人信息”,同时删除《民法典》第1034条第一款。其他如相关法律对于“个人信息处理”或“数据处理”等用语中的“处理”概念的界定也尽量避免冲突。此外,在规制数据跨境流动的法律除了前面提到的外,《消费者权益保护法》《电子商务法》及最高院《关于审理使用人脸识别技术处理个人信息相关民事案件适用法律若干问题的规定》(2021年6月8日)及我国批准或加入的条约等均有规定,如何通过协调给出一个详尽、严格、协调的法律管控的范围与体系,使相关主体在数据获取、运用、管理、保护等方面容易合规,是一个庞大的工程。

其次,把现有涉及数据跨境流动的政策中的合理内容及行政法规或部门规章中符合规律的条文上升为法律。前者如“数据二十条”中提出的“数据跨境流动安全”的内容,建立合规高效、促数据进使用和流通、场内外结合的数据要素流通和交易制度,完善数据流通规则……有序发展数据跨境流通和交易,建立数据可信流通体系(含数据来源可确认、使用范围可界定、流通过程可追溯、安全风险可防范)及数据安全合规有序跨境流动机制以便于开展数据交互、业务互通、监管互认、服务共享等方面的国际合作;推进跨境数字贸易基础设施建设,以《全球数据安全倡议》为基础,积极参与数据流动、数据安全、认证评估、数字货币等国际规则和数字技术标准制定。坚持开放发展,推动数据跨境双向有序流动,鼓励国内外企业及组织依法依规开展数据跨境流动业务合作,支持外资依法依规进入开放领域,推动形成公平竞争的国际化市场。统筹数据开发利用和数据安全保护,探索建立跨境数据分类分级管理机制。对影响或者可能影响国家安全的数据处理、数据跨境传输、外资并购等活动依法依规进行国家安全审查。按照对等原则,对维护国家安全和利益、履行国际义务相关的属于管制物项的数据依法依规实施出口管制,保障数据用于合法用途,防范数据出境安全风险。探索构建多渠道、便利化的数据跨境流动监管机制,健全多部门协调配合的数据跨境流动监管

体系。反对数据霸权和数据保护主义,有效应对数据领域“长臂管辖”的滥用。上述政策为相关法律法规的完善提供了重要指南和参考。后者主要涉及现有的行政法规或部门规章,如 2025 年 1 月 1 日生效、共 64 条的《网络数据安全管理条例》中的相关规定,在时机成熟时,可以提升为法律;再如其在总结《数据出境安全评估办法》《个人信息出境标准合同办法》《促进和规范数据跨境流动规定》等部门规章制定实施经验基础上,作出的关于高效便利安全的数据跨境流动机制,特别是网信部门统筹协调有关部门建立国家数据出境安全管理专项工作机制,协调处理网络数据出境安全重大事项、网络数据处理者通过数据出境安全评估后向境外提供个人信息和重要数据的限制、网络数据跨境安全管理规定等。还有数据的分类分级等规范也应上升到法律的高度。

对我国数据跨境流动监管思路的重申及《促进和规范数据跨境流动规定》^①规定了“豁免”的情形,可以列入法律中。除个人信息和重要数据外,核心数据、国家秘密等与国家安全紧密相关的数据以及特定行业领域项下规范的特殊类型数据仍处于数据跨境流动监管的框架下,需满足其他相关法律法规的要求才可跨境流动。

三是构建从法律到行政法规再到部门规章及标准等软法性质体系性规制,同时适当兼顾中国批准或加入的条约之规范,以便于各主体特别是企业在数据跨境流动中所面对的前文提及的隐私保护、国家安全及经济发展等方面所面对的风险。虽然我国数据跨境流动领域的规制体系已形成了“法律-行政法规-部门规章”多层架构,以国家安全、公共利益和个人信息权益保护为核心,兼顾促进数据依法有序自由流动,但尚未形成完整的法律体系。法律方面,《民法典》作出了原则性规范,^②前文提及的网络安全、数据安全及个人信息等三个基本法律就特定领域作出了较为具体的规范。行政法规方面,对应三个法律的实施条例中,已经出台《网络数据安全管理条例》(2025 年 1 月 1 日起施行)^③,其他两部是否也应尽快出台?^④2021 年 9 月实施的《关键信息基础设施安全保护条例》,明确 CII 运营者本地化存储义务;CII 数据出境须通过国家网信部门安全评估。再次是部门规章、规范性文件及标准等等,目前有 25 个左右,如国家互联网信息办公室通过的《数据出境安全评估办法》,2024 年 3 月 22 日起施行的《促进和规范数据跨境流动规定》,2022 年 9 月 1 日起施行的《数据出境安全评估办法》,2023 年 6 月 1 日起施行

的《个人信息出境标准合同办法》及 2022 年 11 月 18 日发布的《个人信息保护认证实施规则》等,但这些还远远不够,随着技术的复杂性以及面对日益出现的数据跨境的不同场景和不同领域,部门规章、数据跨境流动的具体措施和标准需要日益丰富。

(二) 国际层面:积极参与、推动和引领数据跨境流动国际规则的完善

中国作为数据大国,在数据跨境流动领域,与美国有诸多共同的地方,美国今天碰到的问题,将来也是中国可能碰到的问题。中美同频,在数据跨境流动规制方面应加强合作,而非与欧盟及其他数字弱国过分强调数字权利保护等一起对抗美国。中国的地位较为特殊,两方面都可以兼顾,在美国、欧盟等之间可起到桥梁纽带作用,以促使各方接受利于数据贸易发展的全球性多边机制。实际上,数据本地化与数据跨境流动之间并不矛盾,处理妥当,可以促进安全与发展、经济贸易之间良性互动关系之形成。

1. 尊重现有的多元价值及体系,推动区域性数据跨境流动机制的完善

在数据本地化存储规则方面,形成与 DEPA 各国立法互相尊重的透明规则,推进与 DEPA “本地化为原则+合法公共政策为例外”的数据跨境本地化模式的制度衔接。^[29]求同存异是当下数据跨境流动国际法规制对多元规制给予承认和尊重的基本态度;突出“中国参与或引领”,意指我们能够提出在数据跨境流动领域的共同规律或价值基础上的中国方案。为此,尊重现有的多元价值及其体系中的合理成分,如欧盟体系下突出对相关主体的权利保护、美国突出的数据有限自由跨境流动的价值观^⑤及发展中国家的本地存储等合理要求等;积极加入高标准数据跨境流动的区域性协议并积极推动与中国有关的区域性条约的形成或完善,将体现数据跨境流动中的共性部分或规律的中国方案纳入相关协议中是当下现实可行的。如在已经形成的区域性多边协议方面,RCEP 已经体现出中国的作用。可以进行区域性的多边谈判,将中国的一些好的做法法制化,然后在周边国家或区域层面推行。中国的实践是数据处理器必须确保数据的外国接收者提供了不低于《个人信息保护法》规定的保护要求;根据数据处理器基于其拥有的数据的敏感性和数量的分类,可能适用其他要求。拥有大量个人数据的处理者和关键信息基础设施运营者必须完成由中国网信办领导的强制性安全审查,然后才能将任何数据传输到海外。如注重兼顾数据跨境的隐私保护、安全保障与经济贸

易发展之间的协调,政府和公共数据跨境的同意要求,数据本地化存储的适宜和数据删除要求,向第三方和海外传输个人信息的限制及一般合规要求;明确重要数据出境安全监管的工作协调与统筹机制,建立“数据分类分级保护制度”,明确“国家核心数据”管理制度,网络安全等级保护制度与数据安全保护制度的衔接;严格规制面向境外司法或者执法机构的数据出境活动,完善政务数据跨境的相关规定及明确数据处理活动不应排除、限制公平竞争等。这些吸纳不同法域数据跨境流动合理因素的措施,很值得在有关区域性协议中作出规定与完善。例如,上海自贸区的数据跨境新规允许自由贸易区在国家数据分类分级制度框架下,制定需要纳入数据出境三条路径的“负面清单”,该负面清单经省级网络安全和信息化委员会批准后,报国家网信部门、国家数据管理部门备案后实施。^[3]这个经验也值得在区域性协议中推广。数据跨境流动的国际规制第一步就是短期内,推动 RCEP、DEPA 与 CPTPP 等规则之间的相互协调,以“白名单+负面清单(豁免)”的方式促进相关数据的跨境流动。^[3]

数据流动蕴含利益的多样性和交织性,涉及个人、企业、社会和国家,这给一国的数据跨境监管政策带来了挑战;区域性决定了在文化、地缘等方面如具有相似性,不同主体参与更易推动合作的完成。我们应鼓励多元主体积极参与区域性数据跨境流动机制建设,促使政府、政府间国际组织、企业、民间机构等各主体坚守共商共建共享理念,发挥各自作用,推动全球数据跨境流动合作,携手构建高效便利安全的相关机制,打造共赢的数据领域国际合作格局,推动数字红利惠及各国人民。^[6]在这方面,由于大数据公司的种种状况及其优势,在数据跨境流动国际法规制领域对它们作用的发挥应给予足够的重视。

2. 寻求全球性多边机制的形成

中国在全球性多边协议形成方面,可以积极努力。中美两个数据大国之间的合作将便利统一多边的国际规则的形成。当下两国就数据跨境流动的立场趋同,2024年2月起,美国从原先主张“数据自由流动”开始转向支持“国家安全与国内监管优先”,与中国主张的“数据主权+合规出境”趋于一致;这种转变使全球性多边协议达成成为可能。在此基础上,兼顾发展中国家的立场与顾虑,如数据保护能力不足的国家担忧自由流动将加剧数据殖民风险,因而反对强制性条款;对此,我们可以做更具灵活性的处理。在数据跨境流动规则方面,秉持“构建数字空间

命运共同体”的价值理念,强化国际合作筑牢数据跨境流动安全防线,准确把握数据流动和安全发展的平衡点。^[2] 规制的核心不仅在于监管,更在于促进合规流动,发挥数据的价值。建立统一的协调机制以管理数据的跨境流动是各个区域或国家未来经济合作的基础,我国必须主动融入这些规则体系中,才能在经济全球化、自由化中扮演更为关键的角色。^[2]

在目前的体制下,在该领域的全球诸边谈判中,积极推动 WTO 框架下有关数据跨境流动的国际法规则的建立和完善,较有可能。在国际经济贸易领域,WTO 规则在全球范围内最具影响力,具有最强的执行力,在其框架下形成的规则无疑最权威。美国现在对 WTO 规则制定是若即若离,中国可以担当大国责任,利用经济、贸易等软实力,将中华文化“和、合”文华的精髓及“天人合一”的哲学思想以及中国提出的全球四大倡议(安全、发展、文明和治理)中蕴含的理念推广运用到数据跨境流动中。2024年11月20日中国网信办发布《全球数据跨境流动合作倡议》,呼吁各国在尊重数据主权的基础上,推动数据跨境流动的国际合作;倡导秉持开放、包容、安全、合作、非歧视的原则,平衡数字技术创新、数字经济发展、数字社会进步与保护国家安全、公共利益、个人隐私和知识产权等之间的关系,在推动数据跨境流动的同时,实现各国合法政策目标。虽然数据和数字活动本质上是无国界的,但监管不是,保护隐私、数字和国家安全,保护和执行知识产权,促进经济发展等也不是;当数据跨越司法管辖区时,保持监管和审计机构的覆盖范围可能会变得更加复杂。^[3] 积极推动旨在促进跨境数据流动与信任合作的“可信的数据自由流动”(DEFT)之国际倡议,通过全球性多边协议,强调在保障数据安全与隐私的前提下,推动跨国数据共享与合作,以释放数据价值并促进全球经济发展。七国集团通过 DEFT 框架克服跨境数据流动中的监管、本地化存储等障碍,建立信任机制以促进数据自由流动;它提出的实践方向与具体措施包括制定统一的数据保护标准、简化跨境数据传输流程、加强国际合作以应对网络安全挑战,并探索建立国际数据空间等新型合作模式。中国积极倡导的 WTO 框架下《电子商务协议》正在进行中,该协议突出数据跨境流动方面基本原则和理念的形成;^[1] 在今后的谈判中可以融入前述诸多理念和原则,以制定出符合规律、可推动联合国可持续发展目标的实现的公平合理的数据跨境流动国际规则。为此,WTO 框架下对此作出协调意义深远:通

过该协议,让不同区域的数据跨境流动政策从对抗或分歧到“可信任的自由流动”,并实现分层治理,即区分个人数据、商业数据、公共数据等,实行风险分级管理(如中国近期试点“豁免一般数据出境评估”),以解决数据跨境流动的终极矛盾,即数字全球化与国家主权边界的永恒博弈;其中,需关注规则演进的核心点在于将技术中性原则转化为“可信流动”的制度创新;通过“监管沙盒”等机制,逐步推动 GDPR 与 RCEP、CPTPP 规则的兼容性测试;形成主权让渡的补偿机制,在区域协定中建立数据流动收益分配条款(如数字税收共享),缓解发展中国家对“数据殖民”的担忧。

长期地看,由于数据跨境流动不仅仅涉及贸易,还涉及安全、个人隐私、广义上的经济发展等,故比较理想的状况是在联合国平台上,通过统一的数据跨境流动协议,制定全球一般通用规则或标准,在隐私保护、安全、经贸发展等方面设立合理例外条款;^③同时,基于协议成立“数据跨境流动理事会”机构,协调实施该协议。如就安全而言,与国家安全有关的措施通常要求在本地存储和处理数据,以保护被视为敏感的信息,或确保国家安全部门访问和审查任何形式数据的能力;此外,还可以以临时授权为条件的流动,涉及只允许在有关当局审查和批准的情况下逐案传输数据的系统。这种方法涉及与隐私有关的个人数据,但也涉及包括在国家安全背景下、更广泛的“重要数据”类别。^{[3] P8-9} 上述内容,只有通过更

为全面的全球性多边机制才可以完成。

结 语

当下世界不缺财富、资源与技术,缺的是公平合理的国际法律制度,数据领域尤为明显。关于国际法与国内法的关系,过去我们常强调国际法对国内法的影响,但今天我们更应突出国内法对国际法的影响,因为从二者关系发展源头看,往往是国内某一领域的法律规则形成国际法的形成提供前提条件,该规则常能够推动该领域国际法的发展与形成,这在二战后较为明显。从实施角度看,通常是后加入的国家要适用并遵守形成的条约,进而参与其中,有可能影响或修改条约的内容。因此,作为条约的引领者,往往需要从自身的国内法建设开始,且就某一现象的国内规则先强调共性而非个性或所谓的“特色”。针对当下数据跨境流动领域“群雄并举”的局面,中国应从自身出发,首先完善自己的相关制度,为数据跨境流动提供良好的国内法基础,进而影响周边国家或地区及“一带一路”参与国的相应法律制度,为形成符合规律的良性制度起到引领作用,进而做出自己的贡献。人,要养浩然之正气,才能成就事业;国家同样,中国应以人类共同命运和共同利益为基本原则,为国际正义养“国家之浩然正气”,在构建人类命运共同体理念下,推动公平合理、符合数据跨境流动自身规律的国际规则形成,进而实现数据可信任跨境自由流动,造福世界各国人民。

注释:

① 文中“数据跨境流动”与“跨境数据流动”无本质区别,为同一概念的不同表述,即指“数据跨越国家或司法管辖区边界的流动行为”。英文常用“trans-border data flow”或“cross-border data flow”表示。

② 它与信息技术的关系:所有数字技术都属于信息技术,但并非所有信息技术都是数字化的;前者是后者的子集与演进。后者是“骨架”(支撑信息流动的系统),它“让信息可控”,前者是“血肉”(通过数字化赋予智能与效率),它让“让信息可算”。

③ 20 世纪 80 年代,苏联想修建泛西伯利亚天然气管线,面临着资金和技术的双重难题,决定动用克格勃的间谍系统窃取相关技术,被美国中情局通过秘密转让包含隐藏故障技术的软件引爆西伯利亚天然气管道,给苏联带来致命打击。

④ 根据部分德国媒体的调查,“北溪”爆炸案可能不仅是一起物理破坏事件,更是一场信息操控与地缘政治博弈的战场。

⑤ 从中国知网上以“数据跨境流动”为名进行检索可以发现论文标题中含有该词组的期刊论文最早出现于 1998 年程卫东教授发表的 2 篇论文中,之后 2011 年才有相关论文出现,至 2015 年每年均在 4 篇之下;2016 年至 2020 年每年 20 篇左右;2021 年达到 84 篇,去年最多达到 153 篇;属于国际法学科的论文有 182 篇,多从监管、合规、安全等角度探讨相关问题。比较有意思的是,早在 1980 年 9 月 OECD 通过了《关于隐私保护和个人数据跨境流动的指南》(2013 年修订)及 1985 年 4 月 11 日 OECD 成员政府通过了一个《关于数据跨境流动的 OECD 宣言》(2013 年修订),随着信息、计算机及通讯领域技术的发展,OECD 国家敏感地意识到数据跨境流动的不可避免,但其重点在于强调在适度保护好个人隐私的情况下,促进个人数据跨境流动的自由(不能因为个人隐私过度保护而影响数据数据的自由流动);从前述研究状况看,引起学界普遍关注的,却起自 2021 年。See OECD: Recommendation of the Council concerning Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, OECD/LEGAL/0188, <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0188>。

⑥ See Article 12 of Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, European Treaty Series - No. 108, Strasbourg, 28.I.1981. <https://rm.coe.int/1680078b37>。

⑦ See APEC Privacy Framework, Published by APEC Secretariat, APEC#217-CT-01.9, 2017。

⑧ 参见国家网信办《促进和规范数据跨境流动规定》(2023 年 11 月,国家互联网信息办公室令第 16 号)第 3、4、5、10、11 条。

⑨ 参见中国网信网《专家解读:促进和规范数据跨境流动的重要规定》, https://www.cac.gov.cn/2024-03/22/c_1712776625820516.htm。2024 年 6 月 22 日访问。

⑩ 具体规定参见网信办 2022 年 8 月发布的《数据出境安全评估申报指南(第一版)》。

⑪ 2017 年,USITC 将数字贸易产品和服务分 6 大类:互联网基础设施、固定和无线网络通信服务;云计算服务;数字内容、搜索和新闻;电子商务、数字支付和记录;数字技术的行业应用;消费者通信服务和连接设备。上述定义含电子商务平台本身和相关服务,但排除了在线订购实体商品的销售价值及含有数字内容的实物载体商品的销售价值(如通过 CD 或 DVD 出售的图书、电影、音乐和软件)。参见谭观福著《国际经贸规则对数字贸易的规制》,中国社会科学出版社 2024 年版,第 17-19 页。

⑫ 它们在贸易所涉产品和服务的协调、生产、交付等方面发挥着重要作用。

⑬ 也有人认为数字贸易包括数字货物贸易、数字技术贸易、数字服务贸易和跨境数据流动贸易等四类。

⑭ 参见上海数据交易所,商务部国际贸易经济合作研究院《全球数据贸易发展报告(2024)》,第 1 页。

⑮ 参见《个人信息保护法》第 13、14 条。

⑯ 2013 年以来,“斯诺登事件”、“Google 爱尔兰案”(谷歌因侵犯隐私被爱尔兰监管机构调查)等网络与数据安全事件频繁发生。

⑰ 滴滴事件的安全风险主要体现在对国家安全的挑战。包括美国在内的发达国家互联网企业的先发优势,会带来天然的数据本地化存储及全球数据管理权,进而享有国际规则制定的主导权、话语权和解释权。各国数字产业发展严重失衡,如果任由数据从发展中国家积聚到发达国家,可能助长数据霸权的形成,所以严格的数据管制不只存在于中国,也存在于包括印度在内的其他发展中国家。

⑱ 1980 年,国际上第一份有关信息化背景下隐私保护和数据跨境流动的法律文件,提出了数据控制者在收集处理个人数据时的八大原则。

⑲ 2013 年颁布,它包含了一系列原则和实施指南,旨在建立国内隐私法规并促进跨境数据流动。

⑳ 它规定了个人隐私数据保护的九大原则,旨在促进亚太地区电子商务的发展。See 2015 APEC Privacy Framework.

㉑ 它规定遵守《隐私框架》的九项原则的成员国的个人数据可以在成员国之间自由流动。See APEC Cross-Border Privacy Rules System--Politics, Rules and Guidelines, Updated as of November 2019.

㉒ 专门涉及数据跨境流动的双边协定不多,其中最知名的是基于 GDPR 充分性决定下衍生出的遵循欧盟-美国数据隐私框架,由于其主要涉及隐私保护的数据跨境问题,本文不予讨论。

㉓ 参见《数据二十条》第 15 条之规定。

㉔ 该法首次确立关键信息基础设施(CII)数据本地化要求,CII 运营者在中国境内收集和产生的个人信息和重要数据原则上应在境内存储,确需出境须进行安全评估。

㉕ 它明确国家建立数据分类分级保护制度,对重要数据出境实施严格管控,同时鼓励数据依法有序跨境流动。

㉖ 该法确立个人信息跨境提供的四大合法路径——安全评估、个人信息保护认证、标准合同及法律规定的其他条件,并赋予信息主体决定权。

㉗ 参见《民法典》第 111 条、第 127 条、第 1034 条及第 1035 条。

㉘ 个人信息与个人数据的关系:信息是数据的内容,数据是信息的形式;在互联网时代,个人信息被收集、处理和加工,被数据化后以数据的形式体现,并有了新的价值,所以个人信息和个人数据既有关联,又有不同。

㉙ 《个人信息保护法》(2021)第 4 条第 1 款。

㉚ 《网络安全法》(2016 年通过,2022 年修正)第 76 条第 5 项。

㉛ 国家互联网信息办公室《促进和规范数据跨境流动规定》(2024.3.22),国家互联网信息办公室令 2024 年第 16 号。

㉜ 《民法典》(2020 年)第 127 条“法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的,依照其规定”。

㉝ 数据跨境流动专章,明确“安全评估、标准合同、保护认证”三大出境路径;细化重要数据识别、个人信息出境条件;引入豁免条款(如员工管理、紧急避险等)。

㉞ 如《个人信息保护法》第三章“个人信息跨境提供的规则”规定的内容应尽快通过行政法规加以落实。

㉟ 2024 年年底,美国总统发布的第 14117 号行政令《防止有关国家访问美国人的大量敏感个人数据和美国政府相关数据的行政令》等,强调“国家安全”的首要地位。参见深圳市商务发展促进中心《深圳市遭遇贸易摩擦情况年报》(2024 年第 12 期总 41 期),2025 年 1 月,第 64 页。

㊱ 具体内容参见上海市互联网信息办公室、上海市数据局、中国(上海)自由贸易试验区管委会等五单位联合公布的《中国(上海)自由贸易试验区及临港新片区数据出境负面清单管理办法(试行)》(2025 年 2 月 8 日)。

㊲ 中央网络安全和信息化委员会办公室《全球数据跨境流动合作倡议》,2024 年 11 月 20 日。

㊳ 目前 WTO 电子商务协议草案延续了 GATS 第 14 条“一般例外”与“国家安全例外”的路径,允许成员国在以下情况下限制数据流动:保护基本安全利益(如军事、反恐);实现合法公共政策目标(如隐私、消费者保护)。在未来的联合国框架下的多边协议可以在此基础上作进一步的拓展。

参考文献:

[1] 马忠法.技术霸权主义视域下的国际技术转让法律制度与中国应对[J].贵州省党校学报,2023,5.

[2] 李思羽.数据跨境流动规制的演进与对策[J].信息安全与通信保密,2016,1.

[3] OECD. Recommendation of the Council concerning Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data [R]. OECD/LEGAL,1980.

[4] See Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council [R]. Official Journal of the European Communities, 1995.

[5] 东方.欧盟、美国跨境数据流动法律规制比较分析及应对挑战的“中国智慧”[J].图书馆杂志,2019,12.

[6] 张荣楠.数字主权背景下的全球跨境数据流动动向与对策[J].中国经贸导刊,2020,18.

[7] 相丽玲,张佳戎.中外跨境数据流动的法律监管制度研究[J].情报理论与实践,2021,4.

[8] 冉从敬等.国际跨境数据流动治理合作:机理、困境与变革[J].图书馆论坛,2023,9.

[9] 彭磊.数字关税对我国数字市场开放的意义及政策涵义[J].国际贸易,2020,9.

[10] Matthias Bauer et al.The Economic Importance of Getting Data Protection Right: Protecting Privacy, Transmitting Data, Moving Commerce

- [1] European Centre for International Political Economy, 2013, 3.
- [11] Matthias Bauer et al. The Costs of Data Localisation: Friendly Fire on Economic Recovery [J]. ECIPE Occasional Paper, 2014, 3.
- [12] United States International Trade Commission. "Digital Trade in the U.S. and Global Economies, Part 2" [R]. United States International Trade Commission, 2014.
- [13] 蔡跃洲, 马文君. 数据要素对高质量发展影响与数据流动制约 [J]. 数量经济技术经济研究, 2021, 3.
- [14] 葛平原等. 数据跨境流动规制综述 [J]. 信息安全研究, 2025, 2.
- [15] 陈咏梅, 张姣. 跨境数据流动国际规制新发展: 困境与前路 [J]. 上海对外经贸大学学报, 2017, 6.
- [16] WTO. Joint Statement Initiative on E-commerce [EB/OL]. INF/ECOM/87, 2024-07-26.
- [17] 刘宏松, 程海烨. 跨境数据流动的治理——进展、趋势与中国路径 [J]. 国际展望, 2020, 6.
- [18] 蔡昕言. 全球数据跨境流动国际法规制现状、问题及解决 [J]. 争议解决, 2024, 10.
- [19] 杨松, 汪宓. 数据跨境流动国际规则的困境及应对 [J]. 社会科学辑刊, 2025, 3.
- [20] 胡炜. 跨境数据流动的国际法挑战及中国应对 [J]. 社会科学家, 2017, 6.
- [21] 谭观福. 数字贸易中跨境数据流动的国际法规制 [J]. 比较法研究, 2022, 3.
- [22] 汤净. 数据跨境流动国际规则碎片化与协调路径 [J]. 江西社会科学, 2025, 6.
- [23] Kommerskollegium. Navigating Cross-Border Data Flows and the GDPR [EB/OL]. <https://www.kommerskollegium.se/globalassets/publikationer/rapporter/2025/navigating-cross-border-data-flows.pdf>, 2025.
- [24] 张荣楠. 数据跨境流动限制演变为中美 AI 脱钩工具? [EB/OL]. 中美聚焦网 <https://cn.chinausfocus.com/m/43866.html>, 2025, 6.
- [25] 卫志民等. 跨境数据流动治理: 理论逻辑、潜在风险与规制路径 [J]. 行政管理改革, 2025, 2.
- [26] 熊光清. 积极构建高效便利安全的数据跨境流动机制 [J]. 前线, 2025, 2.
- [27] 靳梦戈. 去中心化背景下数字身份识别的法律风险及其应对 [J]. 四川师范大学学报(社会科学版), 2024, 5.
- [28] 马其家, 李晓楠. 论我国数据跨境流动监管规则的构建 [J]. 法治研究, 2020, 6.
- [29] 齐鹏. 中国与 DEPA 数据跨境流动: 规制差异及制度对接探究 [J]. 法学评论, 2025, 3.
- [30] 许多奇. 治理跨境数据流动的贸易规则体系构建 [J]. 行政法学研究, 2022, 4.
- [31] Francesca Casalini, Javier López-González, and Taku Nemoto. Mapping Commonalities in Regulatory Approaches to Cross-Border Data Transfers [J]. OECD Trade Policy Papers, 2021, 248.

International Legal Regulation of Cross-border Data Flows and China's Response

Ma Zhongfa

(Law School of Fudan University, Shanghai 200438)

【Abstract】The trend of cross-border data flows is inevitable, which affects personal privacy, national security, and economic development (including data monopolies). The regulatory measures adopted by different countries or regions in this regard are slightly different: EU focuses on protecting human rights, especially protecting personal privacy; the USA tends to favor the free flow of data by limitation, while China emphasizes the free flow under safe and controllable circumstances. The international legal regulation of cross-border data flows is fragmented, with no globally unified treaty, and relevant norms scattered in regional free trade agreements. The content of the regulation still focuses on national security, personal privacy, and economic development, etc. At the domestic level, China should improve relevant domestic legislation while balancing security, development, and privacy protection principles. Pilot free trade zones should be used to connect with high standard international data trade rules, creating positive conditions for leading the development and improvement of international rules in this field. At the international level, we should actively participate in international cooperation, give full play to the role of existing regional rules, ensure the balance between data protection, regulatory mechanism optimization and free data flows, participate in or even lead the formation of international data trade rules, especially the global multilateral cross-border data flows agreement, to maximize the benefits of data trade and benefit people of all countries.

【Key words】cross-border data flow; international legal regulation; national security; personal privacy

(责任编辑: 孙培福 李 燕)